

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1687/2548

บริษัทเกรียงสินวัฒนา จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 91/1, มาตรา 92/2

บทบัญญัติ ป.รษฎากร มาตรา 91/1 และมาตรา 91/2 หมายความว่า การประกอบกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรในราชอาณาจักรไทยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 244 โดยคำว่า ขาย ในภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นมีความหมายกว้างกว่าคำว่า ซื้อขาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 453 ซึ่งหมายถึงผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยมีค่าตอบแทน แต่คำว่า ขาย ในภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนอกจากหมายถึงการซื้อขายตามมาตรา 453 แห่ง ป.พ.พ.แล้วยังหมายความรวมถึงการจำหน่าย จ่าย หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ด้วย

โจทก์กับ พ. ได้ทำสัญญาต่างตอบแทนเพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของ พ. โดยก่อนทำการก่อสร้าง พ. ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก์จำนวน 38 ส่วนใน 75 ส่วน ต่อมาโจทก์กับ พ. ตกลงยกเลิกสัญญาการร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าว โจทก์จึงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 38 ส่วนใน 75 ส่วนคืนให้แก่ พ. การที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่ พ. โดยไม่มีค่าตอบแทนก็ถือเป็นการขายตาม ป.รษฎากร มาตรา 91/1 (4) แล้ว และที่ดินที่โจทก์ขายให้แก่ พ. นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์มีไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิจการก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ใน การประกอบกิจการ ซึ่ง ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตาม ป.ร้ษฎากร มาตรา 91/2 (6) ประกอบพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 244 มาตรา 3 (5) โจทก์จึงต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบการค้าวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักร กลต่างๆ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทกรมสังกัดกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่จัด เก็บภาษีอากรตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2534 โจทก์ได้ทำสัญญาต่าง ตอบแทนกับนางพริ้มเพรา สุวรรณลาภ กล่าวคือ โจทก์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคาร พาณิชย 4 ชั้น 4 คูหา ในที่ดินโฉนดเลขที่ 117599 จำนวน 75 ตารางวา ณ ตำบล บางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของนางพริ้มเพรา โดยก่อนที่จะ ลงมือทำการก่อสร้างนางพริ้มเพราจะต้องจดทะเบียนให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินแปลงดังกล่าวก่อน และเมื่อทำการก่อสร้างเสร็จจึงจะโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง จำนวน 2 คูหา ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 นางพริ้มเพรา ได้จดทะเบียนให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกล่าวตามสัญญา จำนวน 38 ส่วน ใน 75 ส่วน โดยนางพริ้มเพราเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ทั้งหมด หลังจากนั้นนางพริ้มเพราได้ไปติดต่อธนาคารศรีนคร จำกัด เพื่อขอกู้เงินโดย นำที่ดินแปลงดังกล่าวจำนองกับธนาคาร เมื่อธนาคารอนุมัติ นางพริ้มเพราจึงแจ้งต่อ โจทก์เพื่อขอยกเลิกสัญญาต่างตอบแทนและขอให้โจทก์โอนที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้ แก่นางพริ้มเพรา ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โจทก์ได้ทำการโอนที่ดินแปลงดัง กล่าวคืนให้แก่นางพริ้มเพรา แต่เจ้าหน้าที่กลับลงบันทึกในโฉนดที่ดินว่าเป็นการขาย

เฉพาะส่วน ในการโอนครั้งนี้นางพริ้มเพราเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว โจทก์จึงไม่ติดใจว่าเจ้าหน้าที่จะบันทึกในโฉนดเป็นอย่างไร ต่อมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สรรพากรพื้นที่ 7 มีหนังสือเชิญโจทก์พบและโจทก์ได้ ไปพบตามวันเวลาดังกล่าว โจทก์แจ้งต่อนางวิมลพรรณ ธารสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานของ จำเลยว่าโจทก์ไม่ได้ทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด และนางวิมลพรรณเห็นด้วยกับโจทก์ แต่เมื่อทำการประเมินกลับประเมินว่าเป็นการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้าหรือหากำไร ต่อมาโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เลขที่ 2007070/6/100185 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 โดยให้โจทก์ ไปชำระภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเงิน 28,125 บาท เบี้ยปรับ 56,250 บาท เงินเพิ่ม 28,125 บาท ภาษีส่วนท้องถิ่น 11,250 บาท รวมภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้นเป็นเงิน 123,750 บาท โจทก์เห็นว่า การประเมินของจำเลยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วย กฎหมาย โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าการ ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการถูกต้องและชอบแล้วแต่ให้ลดเบี้ยปรับคง เรียกเก็บ 39,375 บาท ภาษีส่วนท้องถิ่น 3,937.50 บาท รวมลดให้เป็นเงินทั้งสิ้น 43,312.50 บาท และเรียกเก็บเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเงิน 28,125 บาท เบี้ยปรับ 16,875 บาท เงินเพิ่ม 28,125 บาท และภาษีส่วนท้องถิ่น 7,312.50 บาท รวมเรียก เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเงินทั้งสิ้น 80,437.50 บาท โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และของลดหรือลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีส่วนท้องถิ่น

จำเลยให้การว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 117599 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นการของนางพริ้มเพรา สุวรรณลาภ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 นางพริ้มเพราได้จดทะเบียนให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน

แปลงดังกล่าวจำนวน 38 ส่วนใน 75 ส่วน เพื่อเป็นประกันความเสียหายของโจทก์ในการลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 4 คูหา บนที่ดินแปลงดังกล่าวตามสัญญาต่างตอบแทน และหากโจทก์ทำการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จนางพริ้มเพราจะแบ่งอาคารพาณิชย์ จำนวน 2 คูหา เพื่อเป็นการตอบแทนในการลงทุนของโจทก์และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าของโจทก์ แต่ต่อมาโจทก์และนางพริ้มเพราตกลงเงื่อนไขผลตอบแทนกันไม่ได้ โจทก์จึงโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของโจทก์คืนให้แก่นางพริ้มเพราเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2534 โดยนางพริ้มเพราเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งหมด แต่ไม่มีการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในประกอบการกิจการ ผู้ขายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 91/10 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าผู้ขายอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ สำหรับกรณีของโจทก์ เจ้าพนักงานของจำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของโจทก์คืนให้แก่นางพริ้มเพราเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 นั้น ถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม และเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในประกอบการ อันเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2 (6) ประกอบมาตรา 3 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 เนื่องจากตามสัญญาต่างตอบแทนระหว่างโจทก์กับนางพริ้มเพราระบุให้โจทก์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 4 คูหาเรียบร้อยแล้ว นางพริ้มเพราจะแบ่งอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา ให้แก่โจทก์เพื่อเป็นสถานประกอบการของโจทก์เป็นการตอบแทน อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มุ่งประโยชน์ในทางการค้าจึงเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจ

เฉพาะดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่โจทก์ก็ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใด โจทก์จึงต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินดังกล่าวที่กรมที่ดินกำหนดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 6 (2) กรณีราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินให้คำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ดังนั้น เจ้าพนักงานของจำเลยจึงถือราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นราคาขายที่นำไปคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ จำนวน 937,500 บาท คิดเป็นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 28,125 บาท การที่โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะโจทก์จึงต้องชำระเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งในเดือนภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (2) ประกอบมาตรา 91/21 (6) แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีและโจทก์ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโต้สวนเป็นอย่างดีจึงพิจารณาลดเบี้ยปรับลงคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ส่วนเงินเพิ่มไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายให้งดหรือลดได้ นอกจากนี้โจทก์ยังต้องชำระภาษีส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มนั้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า การที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์คืนให้แก่นางพริ้มเพราสุวรรณลาภ นั้น เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไร อันจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) บัญญัติว่า "ขาย หมายความว่ารวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยนให้ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่" มาตรา 91/2 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้...

(6) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา" พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 บัญญัติว่า มาตรา 3 "ให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร มีดังต่อไปนี้...

(5) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในประกอบการแต่ไม่รวมถึงที่ดินที่ผู้ขายใช้ในการเกษตรกรรม"

บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า การประกอบกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไรในราชอาณาจักรไทยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 244 โดยคำว่าขาย ในภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นมีความหมายกว้างกว่าคำว่า ซื้อขาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 ซึ่งหมายถึงผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยมีค่าตอบแทน แต่คำว่า ขายในภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนอกจากหมายถึง

การซื้อขายตามมาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วยัง
หมายความว่ารวมถึงการจำหน่าย จ่าย หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามนิติกรรม
สัญญาประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมียาค่าตอบแทนหรือไม่ด้วย คดีนี้ข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2534 โจทก์กับนางพริ้มเพราได้ทำสัญญาต่าง
ตอบแทนเพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของนางพริ้มเพรา เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2534 ก่อนทำการก่อสร้างนางพริ้มเพราได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด
เลขที่ 117599 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์จำนวน
38 ส่วนใน 75 ส่วน ต่อมาโจทก์กับนางพริ้มเพราตกลงยกเลิกสัญญาการร่วมลงทุน
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าวโจทก์จึงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 117599
จำนวน 38 ส่วนใน 75 ส่วน คืนให้แก่นางพริ้มเพรา เห็นว่า การที่โจทก์โอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่นางพริ้มเพราโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ถือเป็นการ
ขายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) แล้ว และที่ดินที่โจทก์ขายให้แก่นางพริ้ม
เพรานั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์มีไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิจการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบ
กิจการ ซึ่งถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 91/2 (6) ประกอบพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 244 มาตรา 3 (5) โจทก์
จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ให้นำบทบัญญัติแห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 มาตรา 4 (5) มาปรับใช้กับคดีนี้นั้น
เห็นว่า มูลคดีนี้เกิดในปี 2535 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 342 ยังไม่มีผลใช้บังคับ
จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 342 มาปรับใช้กับ
คดีนี้ได้ สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อสองที่อุทธรณ์ว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง

“ไม่อาจคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากโจทก์นั้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว จำเลยจึงคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามฟ้องจากโจทก์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น”

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ทองหล่อ โฉมงาม-เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>